

1501060-12.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501060-12.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501060-12.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108944/2022 - 04º D.P. GUARULHOS, 24454230 - 04º D.P.

GUARULHOS, 2108944 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Vistos.

VISTOS.

MARCOS VINICIUS DA SILVA ALVES BITENCOURT e LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de abril de 2022, por volta das 10h15, na Rua Débora Oliveira de Almeida, nº 250, Bairro Parque Maia, nesta cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso de agentes com unidade de desígnios entre si, transportavam, para fins de tráfico, 48 porções com 24,2g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi oferecida (fls. 112/117). Os réus foram notificados (fls. 174 e 185) e apresentaram respostas à acusação (fls. 179; 193). A denúncia foi recebida (fls. 201/202) e, não tendo ocorrido absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante essa instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e os réus foram interrogados ao final.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo penal, a representante do Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela parcial procedência da ação penal, condenando-se o réu Leonardo nos termos da denúncia e absolvendo-se o réu Marcos, por insuficiência de provas. Com relação à dosimetria da pena do acusado Leonardo, manifestou-se pela possibilidade de aplicação do redutor, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição de ambos os acusados nos termos do artigo 386, VII do CPP e, subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea de Leonardo e da menoridade relativa de Marcos, aplicação do redutor, 33, § 4º, da Lei de Drogas, regime inicial aberto e, por fim, os benefícios da gratuidade judiciária.

É O RELATÓRIO.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade e autoria do delito ficaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e seguintes), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo laudo de constatação provisória (fls. 36/38), pelo laudo do exame químico toxicológico definitivo (fls. 141/143 positivo para cocaína), e pela prova oral colhida.

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a confissão de Leonardo e as circunstâncias da posse evidenciam que o entorpecente seria fornecido a terceiros. A conduta corresponde, perfeitamente, ao tipo penal do art. 33, da Lei 11.343/06. A autoria é igualmente indubitosa, considerando todo o conjunto probatório. Enquanto ficou certa com relação ao réu Leonardo, a esqualidez probatória acerca do envolvimento de Marcos impõe a sua absolvição.

O réu Marcos negou a prática delitiva, afirmando que tinha entrado no carro e fumado um baseado com Leonardo, quando foram abordados pela polícia e o colega arremessou a sacola com drogas que retirou surpreendentemente do banco. Alegou desconhecimento do material e da troca das placas do veículo. Admitiu que já esteve preso e que estava cumprindo condicional por causa de uma condenação anterior por tráfico. Declarou que consegue tratar o vício se for solto.

O réu Leonardo confessou plenamente a prática delitiva, admitindo que entregaria o entorpecente para terceiro. Alegou que se comunicou com Marcos e o encontrou em sua casa para fumarem um baseado. Negou que ele tivesse conhecimento dos entorpecentes apreendidos. Afirmou que não sabiam das trocas das placas, porque havia pegado emprestado o veículo apenas para trabalhar como Uber para o dono. Não forneceu seus dados.

A negativa de Marcos não foi refutada pelas provas colhidas, ao passo que a confissão de Leonardo encontrou sólido respaldo probatório.

O policial Diogo asseverou que se depararam com o veículo “insulfilmado” em

situação suspeita e tentaram a abordagem. O motorista chegou a baixar o vidro, mas parcialmente. Em seguida, engatou e tentou sair do local, mas o carro morreu. Abordaram ele e o passageiro e localizaram do lado deste no chão, fora do veículo, uma sacola com os entorpecentes. O motorista Leonardo confessou que havia arremessado e confirmou que Marcos estava apenas pegando uma carona. Marcos também afirmou que iria apenas usar entorpecente com o corréu. No porta-malas do veículo encontraram as placas, pois ostentava outras falsas. Fizeram a pesquisa e a proprietária do automóvel correspondente estava em casa com esse em seu poder. O carro tinha sido alugado por terceiro e o réu Leonardo afirmou que havia pegado emprestado.

O policial Jeferson, no mesmo sentido, esclareceu que o motorista tentou fugir da abordagem e jogou algo pela janela do passageiro. Constataram que eram dois pacotes com porções de cocaína. Ele confessou que havia arremessado e que a droga lhe pertencia, isentando Marcos. Este também disse que estava apenas dando "um rolê" com o motorista. O veículo ostentava placas de outro e as suas originais estavam no porta-malas.

Inicialmente, com relação ao acusado Marcos não restou comprovado, em juízo, que ele sabia do transporte do entorpecente realizado por Leonardo. O réu jamais confessou a ciência do ilícito. Não sofreu delação. Os testemunhos não reportaram contato com o material, ao menos visual, antes do abrupto arremesso pelo colega. A hipótese de que foi surpreendido por esse, quando notou a iminente intervenção policial e retirou do lugar de ocultação, sob o banco, não foi infirmada cabalmente.

Assim, não é possível refutar a alegação de que Marcos somente acompanhava Leonardo para fumar um "baseado". Destarte, nesta sede, é insegura e temerária sua condenação. Nenhum outro elemento de convicção sobre a culpabilidade foi coligido aos autos. É cediço que a condenação não se pode fundar somente em frágeis indícios iniciais de autoria, sendo imprescindível a colheita de provas que os corroborem, sob o contraditório, o que não ocorreu aqui. É princípio basilar do Direito Penal Moderno, previsto no inc. LVII do art. 5, da Constituição Federal, a não consideração prévia da culpabilidade. Assim, presume-se inocente o réu até que se prove o contrário.

E, no caso concreto, o contrário não restou provado, em juízo, permanecendo irrelevantes quaisquer suspeitas ou antecedentes do acusado Marcos. Por seu turno, provas foram trazidas aos autos, mas frágeis, aplicando-se o inciso VII e não outro do art. 386, CPP. Não permitem a segura conclusão quanto à responsabilidade penal do acusado Marcos, restando insuperáveis dúvidas acerca da autoria delitiva, o que impõe a absolvição, haja vista o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra do "in dubio pro reo". Destarte, urge reconhecer que os indícios existentes contra o réu Marcos, quando do oferecimento da denúncia, não se transformaram, na instrução judicial, em prova firme e bastante para amparar uma decisão condenatória.

Por outro lado, quanto ao acusado Leonardo, os fatos narrados na exordial acusatória restaram devidamente comprovados. Na data aludida, apoderou-se de dezenas de porções contendo cocaína, colocando-as em duas sacolas distintas e utilizando o veículo VW/Voyage, cor branca, placas originais RFJ9I76, para seu transporte, no qual foram colocadas outras placas (QPX7J10), certamente para frustrar ou dificultar a elucidação completa dos fatos. Entretanto, policiais militares que efetuavam patrulhamento de rotina suspeitaram do veículo, em especial por causa da presença de película escura, e efetuaram a abordagem. Leonardo dispensou a droga, mas a atitude foi vista pelos policiais, que apreenderam o material ainda no local. Em juízo, Leonardo confirmou a prática delitiva.

Com efeito, observa-se que a confissão judicial encontrou sólido amparo nas provas produzidas. Não permaneceu isolada e foi corroborada por várias declarações. Nenhum

dado concreto a abalou. Não há que se falar, portanto, em eventual insuficiência - por seu valor relativo - da confissão judicial, já que esta, no caso dos autos, está amparada por vários elementos probatórios, mormente depoimentos harmônicos. Nesse sentido, transcreve-se lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(..) a confissão ganha qualquer outra prova. Até certo ponto ela as transcende; elemento no cálculo da verdade, ela é também o ato pelo qual o acusado aceita a acusação e reconhece que esta é bem fundamentada; transforma uma afirmação feita se ele em uma afirmação voluntária. Pela confissão, o próprio acusado toma lugar no ritual de produção da verdade penal”. (Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: RT, 2012, p. 470).

E no caso em apreço, os testemunhos atestaram, em uníssono, com detalhes, coerência e firmeza, a posse das drogas pelo réu e confissão, revelando plena adesão ao tráfico, enquanto a defesa não soube relatar dinâmica diversa convincente e não cogitou de motivo para ser supostamente incriminado falsamente. Não é crível, outrossim, que aquela quantidade de cocaína se destinaria apenas ao uso pessoal, sobretudo em condições de transporte e em porções. Assim, não obstante os argumentos da Defesa, as provas da dinâmica dos fatos exposta na exordial são fartas, concluindo-se seguramente pela autoria e dolo.

Além disso, não há razão concreta para desprezar as declarações de testemunhas sob compromisso formal. Saliente-se que merecem crédito e são dotados de valor probatório determinante, em delitos de tal jaez. Nesse sentido, há farta jurisprudência:

“O valor de depoimento testemunhal de policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC nº 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.1996).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM TESTEMUNHOS PRESTADOS POR POLICIAIS. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. (...) 2. Não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese, em que a expressiva quantidade de droga apreendida - 24 (vinte e quatro) invólucros com crack - revela não ser o entorpecente destinado a consumo próprio. 3. Tem-se por adequado o regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal de 5 (cinco) anos aplicada ao paciente pelo tráfico de drogas, dado o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal em conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, não se olvidando a quantidade de entorpecente que trazia consigo. 4. Ordem denegada.” (STJ, HC n.º 223086 / SP; 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013).

E o decreto condenatório não se baseia tão somente na palavra de policial, confissão ou nos dados do inquérito. No caso concreto, todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial sobre a dinâmica da obtenção dos elementos sensíveis da infração, sendo certo que o magistrado pode utilizar todos na formação de seu convencimento. Ainda que assim não fosse, não há óbice à valoração, embora relativa, dos elementos colhidos na fase de investigação para fundamentar eventual decreto condenatório, porquanto a

vedação legal é no sentido da impossibilidade de condenação lastreada exclusivamente em tais provas, nos exatos termos do art. 155 do CPP. Neste sentido, é a jurisprudência:

“(...) Mostra-se válida a condenação imposta com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser afastado de pronto. No caso dos autos a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida, mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do réu, conforme acima exposto”. (TJ/SP, Apelação nº 0039765-66.2010.8.26.0506, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 28/04/2016).

Nesse sentido, os relatos dos policiais devem prevalecer sobre a eventuais impugnações genéricas da defesa, pois foram coerentes nas duas fases processuais, minuciosos, harmônicos, seguros e condizentes com os elementos sensíveis da infração. Também não sugeriram indícios de que a droga pertencesse a outrem ou de equívoco ou ainda vício no flagrante.

No mais, em delitos de tal natureza, as evidências são determinantes para elucidação do vínculo subjetivo entre o agente e as drogas e de sua destinação, sendo inviável prova concreta e cabal do seu pensamento. De outro lado, não se alegou pronta e espontaneamente e não ficou evidenciado que toda aquela droga apreendida seria consumida.

De qualquer sorte, a quantidade e forma de acondicionamento da droga, a confissão espontânea e as circunstâncias da ação revelaram sobejamente a destinação a terceiros. Incabível, pois, eventual tese de insuficiência de provas ou desclassificação para art. 28, da lei. O acusado Leonardo é imputável e praticou os atos típicos descritos na norma penal. Justificativas relativas à situação econômica ou de vício, ainda que, em tese, tivessem contribuído para a traficância, não são dirimentes da ilicitude ou da culpabilidade. Não autorizam a despicienda ofensa ao bem jurídico.

Finalmente, nenhum álibi restou comprovado de maneira inequívoca e nenhuma excludente ficou configurada. Não pairam dúvidas sobre o liame subjetivo entre o réu e as drogas encontradas e sobre a finalidade de fornecimento a outrem.

Portanto, comprovada a materialidade delitiva e evidenciada a autoria, ante o complexo probatório robusto e coerente produzido nos autos, impende apreciar a dosimetria da pena, fixando-a no patamar suficiente e necessário à reprovação do delito.

Bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, consistente em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando a primariedade.

Na segunda fase, prejudicada a análise da circunstância atenuante da confissão, ante a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, tendo em vista a primariedade do réu e a ausência de indícios de envolvimento em organização ou dedicação à atividade criminosa, adota-se a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em 1/3, totalizando 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa.

À míngua de critérios seguros e explicitamente estabelecidos para a aplicação do art. 33, par. 4, da Lei 11343/06, o art. 42 do referido diploma legal deve orientar o patamar daquela redução. Restringir este preceito à fase do art. 59, do Código Penal, a par de despiciendo, criaria distinção injustificada em relação a outros delitos, na primeira etapa de dosimetria da pena, e não permitiria solução eficaz para a controvérsia acerca dos critérios de redução da terceira fase.

Por conseguinte, no caso em apreço, ante a quantidade e a natureza da droga, não se exige a redução máxima, estando preservado o prudente arbítrio do julgador. A propósito, a lei estabelece somente que as penas “poderão” ser reduzidas. Além disso, entende-se que por se tratar de causa de redução como simples benefício – que já pode ir aquém do mínimo legal – e não de dosimetria da primeira fase, não se adota a pena menor em perspectiva (diminuição máxima) como regra. Muito pelo contrário, a legislação recente destinou-se ao agravamento da coibição, da repressão e da resposta penal para o tráfico de entorpecentes, sendo ilógica e dissociada do princípio da razoabilidade a exigência peremptória da diminuição máxima da pena, que a levaria a um patamar muito inferior ao da lei antiga.

Segundo exegese sistemática e teleológica das normas sobre a matéria, o percentual de diminuição deve ser escolhido de acordo com o caso concreto e a especificidade do potencial lesivo da conduta, como possível número de usuários em perspectiva. A confissão revelando sinceridade, disposição de se corrigir e algum arrependimento, além da função do réu no tráfico citado (ausente prova de efetivo comando e gerência na região), por outro lado, não exigem a redução mínima.

Assim, para a pena definitiva de 3 anos e 4 meses de reclusão, cabe o regime inicial aberto para o cumprimento, tendo em vista ainda o “privilégio”, a natureza do crime (sem violência ou ameaça que poderia exigir o fechado), as circunstâncias favoráveis do artigo 59, do CP, e a confissão. Por se tratar de tráfico de drogas privilegiado, cumpre observar decisões recentes dos Tribunais Superiores no sentido de que o referido crime não é hediondo e enseja regime compatível com a quantidade da pena, sem prejuízo da possibilidade de outro mais gravoso (aqui aberto) em razão de fatores específicos, ausentes no caso concreto. Sobre a temática, confira-se:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE”. (STJ, HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1) - Decisão Monocrática- Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

Ademais, tal conclusão também decorre da Lei de Execuções Penais, com as alterações trazidas pelo pacote anticrime (Lei n.º 13.964/2019), mais precisamente da redação art. 112, § 5º da LEP: “Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.”

Preenchidos, por conseguinte, os requisitos do art. 44 do CP, à luz da pena aplicada e da primariedade, sendo ainda socialmente recomendável, concede-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,

consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena a uma entidade com função social, e prestação pecuniária de um salário mínimo especificadas oportunamente pelo juízo da execução.

Ante todo o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Órgão Ministerial para CONDENAR o réu LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na pena privativa de liberdade de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação gratuita de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade com função social, em condições especificadas na execução, além de 333 dias-multa pelo valor unitário mínimo. E ABSOLVO o réu MARCOS VINICIUS DA SILVA ALVES BITENCOURT das imputações expostas na inicial, com fundamento no art. 386, VII, CPP.

Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência em favor do acusado MARCOS VINICIUS DA SILVA ALVES BITENCOURT.

O réu Leonardo poderá apelar em liberdade, pois concedida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Transitada esta em julgado, far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Determino a incineração da droga apreendida, haja vista o encerramento da persecução penal.

Custas e despesas processuais pelo sentenciado Leonardo, respeitada a gratuidade.

P.I.C.

Guarulhos, 04 de outubro de 2022.

Glaucio Roberto Brittes de Araujo

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA